



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione Settima Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado n. R.G. 34447/2020 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* e *Parte_2*
(C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv. Pillosio Valentina,
elettivamente domiciliati in Via Napo Torriani, 33 22100 Como presso il difensore

OPPONENTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio
dell'avv. Martinez Antonello Silverio, dell'avv. Massobrio Massimiliano, dell'avv. Caforio
Assunta, elettivamente domiciliata in Via Archimede 56 20129, Milano

OPPOSTA

La causa - il cui svolgimento processuale è qui sinteticamente riassunto, essendo la sentenza redatta in conformità al canone di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. - è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 aprile 2021, con termini alle parti ex art.190.2 c.p.c., previa precisazione delle seguenti

CONCLUSIONI

Per gli opposenti:

“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare

In via preliminare:

-Rilevato che l'opposizione è fondata su prova scritta e che, in ogni caso, risulta documentalmente che anche l'importo astrattamente e contabilmente esonibile è diverso rispetto a quello invece ingiunto, respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n.7842/2020 n.R.G. 13978/2020 in quanto carente dei requisiti di cui all'art.634 c.p.c. e perché l'opposizione riveste i requisiti della prova scritta ex art.648 c.p.c.;

-Rilevato che l'opposizione è fondata su prova scritta e che, in ogni caso, risulta documentalmente che anche l'importo astrattamente e contabilmente esonibile è diverso rispetto a quello invece ingiunto, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Como, foro di residenza del debitore;

-Previe le declaratorie di Legge e del caso, dichiarare nullo e annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente assolversi i Sig.ri *Parte_1* e *Parte_2* da ogni avversa pretesa e domanda.

Nel merito:

-Previe le declaratorie di Legge e del caso, dichiarare nullo e annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e assolversi i Sig.ri [...] *Parte_1* e *Parte_2* da ogni avversa pretesa e domanda.

In via subordinata:

- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale accertare e dichiarare l'inefficacia, l'insussistenza e/o l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e/o accertata la validità dell'accordo transattivo sottoscritto in data 7.10.2016 tra il Sig. *Parte_3* e la *Controparte_2* accertare e dichiarare l [...] *Parte_3* re [...] *Parte_3*, sia con espresso riferimento all'accordo transattivo sottoscritto in data che all'accertamento della effettiva quota da pagarsi dagli eredi del Sig. [...] *Parte_3* detratti i contributi del *Organizzazione_1* per le ragioni oste in narrativa;

In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva conosciute le difese avversarie, di produrre, dedurre indicare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova testimoniale e indicare testi, e si domanda sin da ora la concessione dei termini ex art.183 c.p.c., VI comma.

Con vittoria di spese ed onorari della presente causa.”

Per l'opposta:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la propria competenza a conoscere della presente controversia per i motivi di cui in atti;

In via preliminare: - stante la tardività nonché la palese pretestuosità e infondatezza dell’opposizione proposta dai Signori *Parte_1* e *[...]* *Parte_2*, non essendo la stessa fondata su prova *s* o soluzione, per tutti i motivi esposti in atti e come meglio, munire il decreto ingiuntivo n. 7842/2020 (R.G. 13978/2020) del 26.06.2020, emesso dal Tribunale di Milano, della provvisoria esecutorietà, ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;

Nel merito: In via principale: - respingere le domande rassegnate dai Signori *[...]* *Parte_1* e *Parte_2*, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i po eglio, e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7842/2020 (R.G. 13978/2020) del 26.06.2020, emesso dal Tribunale di Milano;

In via subordinata:

- nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice adito dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che *Controparte_2* *[...]* è creditrice nei confronti dei Signori *Parte_1* e *[...]* *Parte_2* eredi del Signor *Parte_3*, cia ia spettanza, in virtù delle rette relative alla degenza ed al ricovero del Signor *[...]* *Parte_3* presso la Struttura *Parte_4* della somma di € 105.708

tutti i motivi esposti in atti, e come meglio, (espressamente riservata ogni azione per le ulteriori somme che risulteranno dovute) o di quella diversa maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e benevisa al Giudice Ill.mo, oltre interessi di mora dalla scadenza di pagamento sino al saldo, calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. e, per l’effetto, condannare i Signori *Parte_1* e *[...]* *Parte_2*, ciascuno per la propria quota di spettanza, al a s

favore di *Controparte_2* In ogni caso: - accertata e dichiarata la responsa sensi dell’art. 96, comma III, c.p.c., condannare i Signori *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento in favore di *Controparte_2* itativamente determinata

dall’Ill.mo Tribunale adito, ai sensi della norma sopra citata; - condannare i Signori *Parte_1* e *Parte_2* alla rifusione di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., del presente procedimento (oltre che del procedimento monitorio), oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oltre oneri e accessori di legge (C.p.A. 4%). In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva di meglio precisare, modificare ed integrare le domande e le conclusioni formulate, di depositare documenti ed articolare mezzi di prova nei termini di cui all’art. 183, VI comma, nn. 1, 2, 3 c.p.c.”

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio [...] *Controparte_2* per sentir dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo n.7842/20, emesso dal Tribunale di Milano, con cui è stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di euro 105.708,31 oltre interessi e spese di procedura, pari alla somma delle rate (circa €2.000,00 per ciascun mese) per la degenza del *de cuius* *Parte_3* presso la [...] di S. Maria al Monte, *Pt_4* dal 10.6.2013 al 31.12.2017, data del suo decesso; hanno contestato il valore probatorio delle fatture e per quelle emesse dal 17.6.2013 al 7.10.2016 hanno eccepito il fatto modificativo/estintivo rappresentato dalla transazione raggiunta tra *Parte_3* e *Controparte_2* il 7.10.2016; hanno lamentato il difetto dei requisiti di certezza liquidità esigibilità del credito, con conseguente applicazione degli artt. 1182.4 c.c. – 20 c.p.c. in punto competenza territoriale del foro del debitore (Tribunale di Como); in subordine, hanno contestato l'entità della somma ingiunta per essere la quota sanitaria pari al 50% a carico del SSR e la restante quota alberghiera da suddividersi tra Comune e richiedente la prestazione; hanno concluso per la declaratoria di nullità/annullamento/revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni pretesa; in subordine per la riduzione dell'importo ingiunto per effetto sia della transazione sia dell'intervento di SSR e *Org_2* nel pagamento di parte della retta.

La convenuta si è costituita contestando il fondamento dell'opposizione, di cui ha chiesto la reiezione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna della parte attrice al pagamento della somma ingiunta; ha rilevato come: l'accordo transattivo non sia mai stato sottoscritto; la domanda di accoglienza sia stata siglata da *Parte_3* e da *Parte_1*, che ha anche firmato l'impegno di pagamento delle rette quale garante e il contratto di ingresso del padre nel Centro di

debito sino ad allora maturato.

All'udienza di prima comparizione delle parti il giudice ha rilevato d'ufficio la questione afferente la competenza del foro del consumatore in favore del Tribunale di Como, avendo gli ingiunti residenza in Lurate Caccivio.

I difensori di entrambe le parti hanno chiesto termine per poter prendere posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio.

Il giudice, in applicazione dell'art 101.2 c.p.c., ha assegnato a ciascuna parte termine per depositare una nota contenente le osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio e per formulare le rispettive le istanze in relazione all'udienza a trattazione scritta del 9 marzo 2021. In quella sede, ritenuto di doversi pronunciare in ordine all'eccezione di carattere pregiudiziale, a mente degli artt. 187 c.p.c. - 80bis disp. att. c.p.c. (Cass 4767/16), ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, riservando la decisione in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, come anche la concessione dei termini ex art.183.6 c.p.c., all'eventuale superamento della questione pregiudiziale.

Ad esito dell'esame degli scritti depositati ex artt. 281quinquies-190.2 c.p.c. da entrambe le parti, deve concludersi per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore di quello di Como, con le conseguenti statuizioni.

Invero, la disciplina di cui al d.lgs. 206/2005 prevede all'art. 63 (nella formulazione precedente la riforma introdotta dal d.lgs 21/2014, e che continua ad applicarsi ai contratti conclusi sino al 13.6.2014), quale foro inderogabile per le controversie civili inerenti all'applicazione del capo I ("particolari modalità di conclusione del contratto" (contratti negoziati fuori dei locali commerciali e distanza) quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, vale a dire della persona fisica che conclude il

contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di attività imprenditoriale, artigianale commerciale o professionale, anche solo occasionalmente esercitata (cfr art 3 lett a).

Solo il consumatore può derogare al foro del suo domicilio o residenza; così si esprime infatti la Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Civile, nell'ordinanza 8 febbraio 2012, n.1875. Si legge infatti nella citata ordinanza: *“Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi.*

L'art. 33, comma 2, lett. u), d.lg. n. 206 del 2005 pone una presunzione di vessatorietà della clausola che individua come sede del foro competente, nelle controversie tra consumatore e professionista/imprenditore, una diversa località rispetto a quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Ciò premesso, nel caso di specie, gli opposenti sono stati destinatari dell'ingiunzione quali eredi di Parte_3, nato il 10.4.1926, residente a Varese, il quale, il 29.1.2013 ha avanzato alla CP_2 la domanda di accoglienza – sottoscritta anche dal figlio Parte_1 quale garante (doc 1 monitorio; cfr anche consenso informato sub doc 63 opposta); Parte_1, poi, in pari data, ha firmato la dichiarazione di impegno economico, assumendosi l'onere della retta di ricovero del padre (doc 64 opposta) e il 13 giugno 2013, in forza di procura generale notarile, ha concluso in Pt_4 con Controparte_2 un contratto di ingresso del padre nella

per ricevere le prestazioni descritte all'art. 2 (assistenziali e sanitarie, volte alla socializzazione e integrazione dell'ospite, di animazione, supporto psicologico assistenza religiosa ristorazione lavanderia e stireria pedicure e manicure), stante la perdita dell'autonomia fisica-psichica di *Parte_3* (all'epoca 87 anni) e la mancanza di familiari disposti ad accoglierlo o comunque in grado di occuparsene.

Parte_1, dunque, è destinatario della pretesa creditoria anche in proprio.

Si verte, allora, in tema di contratto di diritto privato, destinato a garantire all'anziano non autosufficiente prestazioni di tipo alberghiero e un' assistenza sanitaria di base (che si traduce nella somministrazione di eventuali farmaci che già risultassero prescritti e nella periodiche visite mediche); invero non è prodotto in atti il fascicolo sanitario né le parti allegano alcunchè in punto stato di salute di *Parte_3* ed eventuali sue condizioni patologiche; può soltanto evincersi, sul piano cognitivo, che il medesimo fosse capace di intendere e di volere atteso che, in vista del suo ingresso nella RSA, *Parte_3* ha rilasciato al figlio procura notarile e ha sottoscritto lui stesso la domanda di accoglienza e il consenso informato. Ne consegue che il contratto è soggetto alla normativa a tutela del consumatore, nel senso che l'utente e chi si è obbligato per lui sono consumatori.

Non rileva che la *CP_2* che gestisce la non abbia fini di lucro né si attaglia al caso di specie l' ordinanza n. 8093/2009 della Suprema Corte di Cassazione citata dalla convenuta che fa riferimento all'erogazione di prestazioni sanitarie in senso stretto presso ospedali pubblici e privati convenzionati con il SSN - mentre nell'ipotesi in esame (per quanto emerso dagli atti processuali) si verte in tema di contratto volto all'ottenimento di prestazioni di mera ospitalità di lunga degenza.

Stante la presunzione di vessatorietà dell'art 12 del contratto di ingresso - che stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per qualsiasi controversia che possa nascere in merito al contratto - sarebbe stata necessaria una doppia sottoscrizione, a

mente dell'art 1341 c.c., e l'allegazione/dimostrazione che la scelta del Tribunale di Milano fosse rispondente alle esigenze del consumatore (cosa che qui anzi è esclusa dal tenore delle difese sul punto degli opposenti); né la mera enunciazione del “comune accordo” raggiunto tra “l'ospite/il legale rappresentante/il garante e la []” a proposito del foro competente è idonea a comprovare che quella pattuizione sia stata frutto di specifica trattativa tra le parti; invero, il contratto è redatto su modulo standard prestampato del centro Malnate destinato a un platea indifferenziata di fruitori del servizio, in cui risultano inseriti a penna negli appositi spazi lasciati liberi, a pag. 1, i meri dati anagrafici dell'ospite e del suo procuratore.

Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto dichiarato nullo perché emesso da Tribunale territorialmente incompetente, competente essendo il Tribunale di Como in relazione al luogo di residenza degli opposenti (Lurate Caccivio), e il provvedimento va assunto con la forma della sentenza (Cass Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14594 del 21/08/2012: “ *In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”).

L'opposta deve rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in dispositivo ex DM 55/14 con la massima riduzione della fase di trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano sezione VII civile in composizione monocratica, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 7842/20 emesso dal Tribunale di Milano, territorialmente incompetente, competente essendo il Tribunale di Como;

condanna l'opposta a rifondere agli opposenti le spese di lite liquidate in € 286,00 per spese, € 9.650,00 per compenso oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA

Milano, 18 settembre 2021

IL GIUDICE

dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti